

1502068-30.2022.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... de liberdade por restritiva de direitos ao crime de tráfico de drogas, trago à colação o julgado do E. STJ:

" (...) 1. A nova Lei de Tráfico de Entorpecentes (11.343/06) dispõe que o delito de tráfico é insuscetível de sursis e, ainda, vedou expressamente a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502068-30.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502068-30.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2129499/2022 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 24930443 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2129499 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME RODRIGO ALMEIDA BISPO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Vistos.

GUILHERME RODRIGO ALMEIDA BISPO DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 18, está sendo processado por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11. 343/2006, porque no dia 12 de maio de 2022, por volta de 12h36, na Rua Plácido Ribeiro Ferreira, nas proximidades do nº 10, no Parque Zabani, nesta cidade de Santa Bárbara d'Oeste, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 33 (trinta e três) porções de Cannabis sativa L (maconha), 07 (sete) porções de cocaína e 12 (doze) porções de crack, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar.

Segundo foi apurado, GUILHERME RODRIGO obteve, por meios ainda não esclarecidos, a posse das substâncias entorpecentes descritas acima, para entrega a consumo de terceiros.

Ocorreu que, os policiais militares realizavam o patrulhamento de rotina pelo local dos fatos e, em dado momento, visualizaram o indiciado que, ao notar a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo, saiu correndo e dispensou algo sobre o telhado de um imóvel.

Diante do comportamento apresentado, o autuado foi perseguido e abordado. Realizada a revista pessoal, em poder de GUILHERME nada de ilícito foi encontrado. Já o objeto anteriormente dispensado foi recuperado e então constatado tratar-se de 33 (trinta e três) porções de Cannabis sativa L (maconha), 07 (sete) porções de cocaína e 12 (doze) pedras de crack, além da quantia de R\$ 128,50 em espécie.

Questionado pelos policiais e interrogado na Delegacia de Polícia, GUILHERME RODRIGO assumiu a propriedade das drogas apreendidas, afirmando que as drogas se destinavam à venda e que o dinheiro era proveniente do tráfico. Alegou, ainda, que estava desempregado e que por isso decidiu vender drogas (fls. 11).

Portanto, as circunstâncias da apreensão das drogas, a quantidade, a variedade, a forma de acondicionamento, o encontro de dinheiro, bem como a confissão informal e extrajudicial do indiciado e o relato dos policiais militares, evidencia que as substâncias entorpecentes pertenciam ao denunciado e que se destinavam a entrega a consumo de terceiros.

O réu foi notificado (fls. 96) e apresentou defesa preliminar (fls.94). A denúncia foi recebida em 21 de julho de 2022 (fls. 97). E o réu foi citado (fls. 123). Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação, interrogado o acusado ao final.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, face a comprovação da autoria e materialidade delitivas, afastando a incidência do reconhecimento do tráfico privilegiado. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por falta de provas ou a desclassificação delitiva para porte de entorpecente para uso próprio.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende pelo Boletim de Ocorrência de fls.12/13, auto de exibição e apreensão de fls.14, auto de constatação preliminar de fls. 15/17, laudo de entorpecentes fls. 127/132, e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é certa.

Os policiais militares Mauricio Trevisan Pinto e Amâncio Colombo Neto deram versões essencialmente iguais. Disseram que estavam em patrulhamento pelo bairro e num ponto de tráfico de drogas, ao final da rua, avistaram o acusado com um invólucro plástico na mão. Ao avistar a viatura, ele fugiu e arremessou esse invólucro sobre uma residência. Foi abordado e com ele havia R\$ 128,50. O morador da residência comunicou que encontrou o invólucro, e constatou-se que em seu interior havia 33 porções de maconha, 07 porções de cocaína e 12 porções de crack. De pronto confessou que estava vendendo drogas para pagar dívida que tinha com traficante.

Não é conhecido dos meios policiais.

O acusado, em seu interrogatório, disse que é usuário de drogas e se assustou quando viu a polícia, porque estava com dois pinos de cocaína que acabara de comprar. Que estava com alguns amigos e fugiu, jogando as droga no telhado de uma casa. Que confessou que estava vendendo porque foi ameaçado.

Em fase policial, às fls. 11, o acusado confessou que estava na posse de todo o entorpecente que foi apreendido, e que se destinava à venda. Que estava vendendo o entorpecente por dificuldades financeiras, e que o dinheiro apreendido era fruto da venda.

A retratação judicial do acusado é isolada e destoante dos demais elementos de prova; não convenceu, muito menos que a confissão extrajudicial foi mentirosa, porque estaria sendo ameaçado por traficantes.

A jurisprudência tem se posicionado quanto à validade relativa da retratação, devendo ser aceita apenas se respaldada no conjunto probatório dos autos:

"Prova criminal - Confissão extrajudicial - Validade, ainda que retratada em Juízo, desde que esteja em consonância com outros elementos de convicção" (RJTJESP, Lex 107/452);

"Prova - Confissão Policial - Retratação em Juízo - Valor relativo - Possibilidade de confrontação com os demais elementos de convicção carreados aos autos a fim de se constatar sua sinceridade - Prevalência da confissão se ressonante no processo - Aplicação do art. 200 do CPP. A confissão policial ressonante no processo prevalece sobre a escoteira retratação judicial" (RT 643/327).

Com relação aos depoimentos dos policiais militares, dou plena credibilidade para firmar meu convencimento, pois restaram uníssomos, coerentes, seguros e isentos, não se observando, em nenhum momento, que eles inventarem uma história apenas com o objetivo de prejudicar o acusado.

Inconcebível querer dar guarida à versão isolada de que os guardas "plantaram" drogas nele. Para tanto, ter-se-ia que acolher a tese de que tais agentes transportam drogas consigo procurando incriminar pessoas inocentes da sociedade, quando lhes conviesse. Tudo isso em conluio com a polícia civil, que em tese repassaria falsamente os depoimentos dos envolvidos para também forjar o flagrante. Esta situação beira o absurdo.

Presume-se que tais agentes sejam homens sérios, dedicados e fiéis cumpridores da lei, dedicados ao difícil ofício de auxiliar a polícia civil e militar no combate à criminalidade local. Para contrapor tal presunção, não bastam meras alegações infundadas; necessário prova concreta e robusta da injustiça da prisão, ou mesmo elementos suficientes que pudessem causar a dúvida no julgador, o que sequer existe nestes autos, pois a alegação de que estava comprando droga no local e que é viciado em entorpecente não foi comprovada, restando portanto, totalmente isolada do restante probatório

Neste cenário, com tranquilidade reconheço a validade e a importância dos depoimentos dos guardas municipais para fundamentar a condenação criminal, pois inexistem elementos para considerá-los indignos.

Nesse sentido, a jurisprudência é farta:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de

agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF, HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello).

“PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente - A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra - Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição - Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido”. (TJSP, Ap. n. 993.07.105623-5 - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery - 06.08.08 - V.U).

“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam declarações como testemunhas em processo criminal, posto que ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório colecionado -Recurso defensivo não provido. (TJSP, Ap.n. 0000179-16.2010.8.26.0411 - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Camilo Léllis dos Santos Almeida - 05/06/2014).

“TJSP. Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (RT 614/275).

A tese defensiva pugnando pela desclassificação para porte de entorpecente para uso próprio fica afastada, pois devidamente comprovada a destinação do entorpecente para a traficância. Ademais, o acusado não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a condição de usuário, o que lhe impunha, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Assim, considerando a quantidade de entorpecente encontrada, a forma de acondicionamento e a confissão informal, tenho como caracterizado o crime de tráfico de drogas, impondo-se, assim, a condenação, nos exatos termos da denúncia.

Passo, então, a dosar a pena.

Primeira fase: Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, observo que o réu ré é primário e não ostenta antecedentes criminais. Por outro lado, o artigo 42 da Lei 11.343/06 dispõe que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, e neste caso em concreto, o réu estava guardando crack, cocaína e maconha. A natureza destes entorpecentes vem em seu desfavor. Trata-se de substâncias que causam imediata dependência e exerce um poder devastador sobre a saúde física e mental do usuário bem superior a outras drogas. Os prejuízos e as consequências nefastas desta droga constituem fatos públicos e notórios, contribuindo efetivamente com o aumento da criminalidade e destruição de vidas e famílias. Por tais razões, quem comercializa este tipo de entorpecente, merece uma reprimenda maior do Estado, conforme nos ensina Renato Brasileiro de Lima: “Como se trata de

crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode equiparar a conduta daquele que é preso com um quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela" (DE LIMA, Renato Brasileiro. Legislação criminal especial comentada, 2ªed., JusPODIVM, 2014, p. 787). Nesse mesmo sentido, têm decidido nossos Tribunais Superiores, fazendo alusão ao princípio da proporcionalidade: "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA. ENTORPECENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente lastreada na quantidade e natureza do entorpecente encontrado em poder do réu - pasta-base de cocaína, de alto poder deletério -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de fundamentação inidônea. 2. Agravo desprovido." (AgRg no REsp 1793804/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). Considerando, assim, tais circunstâncias - natureza do entorpecente - Aumento a pena base de 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal. Na segunda fase de aplicação da pena, Ausentes agravantes e atenuantes Terceira fase. ausentes causas de aumento, porém, o réu faz jus à causa de diminuição de pena por ser primário, de bons antecedentes e não integrar organização criminosas, no entanto, o patamar não se dará pelo máximo porque as circunstâncias apuradas revelam que ele se dedica às atividades criminosas, em especial diante da quantidade elevada de entorpecente apreendida. Ademais, a natureza nefasta do entorpecente comercializado revela maior violação à incolumidade e à saúde pública, o que exige maior rigor estatal para proteção do bem jurídico tutelado, impondo a redução em patamar equivalente à conduta praticada. Registra-se que, a despeito do aumento na primeira fase da dosimetria pela natureza da droga, é possível a modulação da fração pelo redutor ante a natureza dos entorpecentes, não havendo que se falar em bis in idem. Confirma-se recente decisão acerca do tema: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (1Kg DE COCAÍNA). DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, a utilização da quantidade/natureza da droga apreendida para elevar a pena-base (primeira fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (terceira fase), por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosas, não configura bis in idem. Diversa é a hipótese tratada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014) 2. Para se acolher a tese de que o agravante não se dedica a atividades criminosas, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1779825/RO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/05/2019, DJe 23/05/2019). Reduzo, então, a pena de metade, resultando em 02 anos e 11 meses de reclusão e 290 dias multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semi-aberto. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111.840/ES, em 27/07/2012, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. E mais do que isso, no julgamento do HC nº 118533/MS, datado de 23 de junho de 2016, o plenário do STF afastou a natureza hedionda do chamado tráfico privilegiado, sendo plenamente possível, considerando a primariedade do acusado, as

circunstâncias judiciais favoráveis e a quantidade de pena aplicada, fixar o regime de pena intermediário.

Por outro lado, não há como mitigar o juízo de reprovação incidente sobre a conduta delituosa em si mesma, que continua sendo a do tráfico ilícito de drogas, diante das consequências nefastas que causam à sociedade, seja com relação à saúde pública, onde se expõem pessoas inocentes a perderem sua integridade corporal diante do consumo de tóxicos, ou então em razão das demais consequências à sociedade em geral, tal como o financiamento do crime organizado ou a prática desenfreada de delitos contra o patrimônio para a aquisição de tóxicos.

Frente a este panorama, não se pode concluir que regime mais benéfico, neste caso, o aberto, ou a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito sejam suficientes para o real alcance da pena, que deve servir de fator de retribuição ao agente, de readaptação social e prevenção de novas transgressões.

E para o caso do acusado, que estava desempregado e se sustentando através do comércio odioso, procurando obter renda de um jeito mais fácil, o que revela total ausência de responsabilidade e auto disciplina, a substituição por penas mais brandas não lhe é socialmente recomendável.

A respeito do incabimento de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao crime de tráfico de drogas, trago à colação o julgado do E. STJ:

“ (...) 1. A nova Lei de Tráfico de Entorpecentes (11.343/06) dispõe que o delito de tráfico é insuscetível de sursis e, ainda, vedou expressamente a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44). Portanto, cometido o crime na sua vigência, indevida a conversão da pena ou a concessão de sursis. 2. Recente entendimento do colendo STF afirma ser inconstitucional a proibição de conversão de penas em crime de tráfico (HC 97.256, Rel. Min. AYRES DE BRITO); todavia, deve ser ressaltado que foi (a) adotada em sede difusa; (b) por maioria de votos (6x4) e (c) sem efeito vinculante. 3. Não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou (...). (STJ, HC nº 203.403/ SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, d.j. 21/06/2011).

O réu não faz jus ao direito de recorrer em liberdade. Preso em razão do flagrante delito, a Lei nº 11.343/06 veda expressamente a concessão de liberdade provisória para aquele que praticou o crime de tráfico ilícito de entorpecente (art. 44). E ainda que assim não fosse, no presente caso se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. O crime de tráfico de drogas enseja habitualidade e solto, nada impede que volte a delinquir. E o acusado permaneceu preso durante toda a instrução processual, não havendo fato novo apontando a conveniência da sua soltura. E a quantidade de pena aplicada e o regime prisional gravoso exigem a custódia cautelar, para garantir a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para condenar GUILHERME RODRIGO ALMEIDA BISPO DE OLIVEIRA às penas de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semi aberto, e 290 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput e §4º da Lei nº 11.343/06.

Expeça-se mandado de prisão, recomendando-se na que se encontra.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Se o caso, expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para esse espécie processual.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, em favor da FUNAD, pois não comprovada a origem lícita.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: a) oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF; c) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu; c) proceda-se à incineração da droga apreendida, nos termos do parágrafo 1º do art. 32 da Lei de Drogas; d) expeça-se guia de execução penal.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA